

1532585-41.2020.8.26.0451

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII). Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1532585-41.2020.8.26.0451 - Controle nº 2020/000831

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2078230/2020 - 04º D.P. PIRACICABA, 7701524 - 04º D.P. PIRACICABA, 651/18/527 - 04º

D.P. PIRACICABA, 2078230 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAULO JOSE DAS NEVES e outro

Aos 23 de março de 2022, às 14:00h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. ANTONIO CARLOS PEREZ ANTUNES DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: SAULO JOSE DAS NEVES - PRESENTE (via videoconferência)

Réu: ELIANE MARIA DE SOUZA NEVES - PRESENTE (presencialmente)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: ASP VANIAS FIGUEIREDO DIAS - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: ASP DIEGO VILLAS BOAS GONCALEZ - AUSENTE (já ouvida, fls.

155/157)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunhas ASP VANIAS FIGUEIREDO DIAS.

Após, os corréus SAULO JOSE DAS NEVES e ELIANE MARIA DE SOUZA NEVES foram devidamente interrogados.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "ELIANA MARIA DE SOUZA NEVES, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, pois em meados de abril de 2018, por volta das 12h00, no Centro de Detenção Provisória, situado na Rodovia SP 127, nº 104, Areião, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, remeteu, com o objetivo de entrega a Saulo José das Neves, 450g de Cannabis sativa L.1, distribuídos em 01 invólucro, substância entorpecente a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 80/83) SAULO JOSÉ DAS NEVES está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, pois em meados de abril de 2018, por volta das 12h00, no Centro de Detenção Provisória, situado na Rodovia SP 127, nº 104, Areião, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, concorreu para a prática do delito acima descrito Os réus foram notificados, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, os réus interrogados. A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente. A materialidade delitativa foi confirmada nos autos pelos laudos periciais definitivos a fls. 93/95, auto de exibição e apreensão a fl. 05 e fotos a fls. 23, 24 e 26. Da mesma forma, comprovada a autoria delitativa. O réu, na fase informativa, confessou a prática delitativa. Em juízo, negou que soubesse que a droga seria entregue a ele. Já a acusada relatou que o agente penitenciário Vanias disse que abriu a correspondência e sentiu cheiro forte de maconha e constatou que ali havia entorpecente. Informou que quando entrega o sedex, ele é chamado para receber. Não se recordava o que o acusado havia dito na ocasião. Entretanto, informado sobre o teor do seu depoimento de fls. 31 se recordou que o acusado disse que a maconha era transformada em pó e misturada ao achocolatado. Acrescentou que foi o primeiro caso do gênero. Já o agente penitenciário Diego contou que não se recordava muito dos fatos. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na denúncia em relação ao acusado. Com efeito, não obstante tenha negado a prática delitativa em Juízo, na delegacia confessou em detalhes que pediu para um companheiro que "estava de alvará" e passou os dados de sua mãe para ele. Ademais, na ocasião em que a maconha foi descoberta, afirmou ao agente penitenciário que ela era triturada e após misturada com o achocolatado, deixando evidente, assim, que foi ele quem solicitou a remessa do achocolatado com maconha para o interior do estabelecimento penal. Aliás, não haveria sentido que o entorpecente fosse enviado sem o seu conhecimento, como o réu alegou em Juízo. De outro lado, todavia, não ficou claro que a mãe do acusado foi quem remeteu o sedex contendo o achocolatado misturado com maconha, razão pela qual deve ser ela absolvida por insuficiência de provas. Diante do acima exposto, requer-se a procedência parcial da ação, nos termos acima propostos. Na aplicação da pena há que se observar que o réu ostenta Maus antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas (certidões a fls. 90/91), razão pela qual não faz jus ao benefício do §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. A causa de aumento de pena restou demonstrada porque o acusado estava preso em estabelecimento penal na ocasião dos fatos. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao acusado, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. O regime a ser aplicado deve ser o fechado, ante os Maus antecedentes pela prática do mesmo crime e pela gravidade da infração perpetrada".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, os acusados foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal

garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Na audiência anterior, a testemunha Diego, agente penitenciário, declarou que, na época dos fatos, estava afastado de suas atividades. A Juíza informou sobre o caso à testemunha, que disse que isso é uma rotina na Unidade, mas que não se recorda do ocorrido ou do preso. Ratificou, porém, suas declarações. Nesta data, a testemunha Vanias, agente penitenciário, declarou que abriram o saco de achocolatado que tinha sido enviado por sedex para verificar e sentiram um cheiro forte de maconha. Colocaram o objeto na água e perceberam que as folhas de maconha começaram a flutuar. Quando entregam sedex, o pacote é aberto em frente ao preso. Não lembra o que o preso disse sobre isso, mas acredita que ele deve ter negado. Questionado sobre as declarações no Processo Disciplinar, a testemunha disse que se recordava que o preso falou que a maconha era transformada em pó e misturada com achocolatado. Foi a primeira vez que isso aconteceu na entrega do sedex. O réu Saulo, em interrogatório, declarou que sua mãe nunca teria condições financeiras de mandar um sedex, além de ser uma pessoa que precisa de ajuda da sua família para tudo. Tinha que se manter na cadeia fazendo faxina para os outros presos. Não tinha nenhuma ciência de que iria ser remetido um sedex. Questionado sobre as declarações que prestou no Procedimento Disciplinar, o acusado declarou que não se recorda de ter falado o que consta nos autos. Não sabe como as pessoas obtiveram os dados da sua mãe, acha que seria alguém que queria prejudicá-lo. Sua mãe é analfabeta. A ré Eliane, em interrogatório, declarou que os fatos não são verdadeiros. Nunca enviou nada ao acusado por Sedex. Efetuava visitas para o réu. Ele nunca lhe pediu nada. Não sabe escrever nem o seu nome, apenas assina com a digital. Nunca passou os seus dados para outras pessoas, para que mandassem algo para ele. Não conversou com o acusado a respeito dos fatos. Os réus, portanto, negaram a prática do delito. No mais, verifica-se que as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos agentes penitenciários responsáveis pelo recebimento da correspondência, as quais devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança penitenciária do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos agentes, é de se questionar até mesmo a ciência dos acusados a respeito das drogas (em especial a acusada Eliane), eis que eles declararam que nunca tiveram contato com as substâncias e não sabem o motivo pelo qual seus dados foram utilizados na correspondência. Ademais, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. DO ACUSADO SAULO. DO CARÁTER IMPUNÍVEL DA CONDUTA PERPETRADA PELO AGENTE QUE SEQUEU INICIOU A EXECUÇÃO DO CRIME. Excelência, ainda que devidamente demonstrados os fatos, quanto à conduta imputada ao acusado Saulo, sabe-se que, no Brasil, o iter criminis é composto de diversas etapas, porém, as fases da cogitação e dos atos preparatórios não chegam a ser puníveis. Trata-se de etapas internas do iter criminis, cuja punição colidiria com o princípio da materialização do fato ou da alteridade. Aduz o Ministério Público implicitamente em sua denúncia que o acusado Saulo teria

iniciado a execução delitiva. Todavia, não se desincumbiu o Parquet de comprovar os atos executórios a partir da Teoria Objetiva-Formal, expressamente acolhida pelo artigo 14, II, do Código Penal, segundo o qual o crime será tentado quando, "iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente". Como se sabe, segundo a Teoria Objetiva-Formal, somente haverá tentativa se o agente começar a realizar condutas descritas no núcleo do tipo penal, o que, evidentemente, não ocorre com a mera solicitação à sua genitora para que ela encaminhe um objeto com drogas ao estabelecimento prisional. Nesse sentido, mencione-se o posicionamento adotado no Habeas Corpus nº 152.433-SP, julgado pelo STJ em 28 de junho de 2011: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGA TENTADO. ART. 12 DA LEI N.º 6.368/76. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não configura início do iter criminis a ação do Acusado que, estando preso, solicita que lhe sejam levadas drogas, cuja aquisição por ele não se conseguiu comprovar no curso da ação penal. 2. A hipótese seria, no máximo, ato preparatório, via de regra impunível, mas não ato de execução do delito, seja na conduta de "adquirir", a qual se entendeu subsumir a ação do Paciente, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal descrito no art. 12 da Lei n.º 6.368/76, vigente à época dos fatos. 3. No caso, segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, o Paciente solicitou à sua companheira que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido, para "pagamento de dívidas" com outros detentos. Não houve, contudo, a concretização da entrega, em razão de ter sido a droga apreendida na revista que antecedia a visita ao estabelecimento prisional. 4. Ordem concedida para reconhecer a atipicidade da conduta e, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolver o Paciente da imputação contra ele deduzida nos autos da Ação Penal n.º 907/04 - Desmembrado, da 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de São Vicente (SP), cassando, em consequência, a condenação nela proferida e posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n.º 990.08.087358-0. Portanto, mister se faz o reconhecimento de que o fato imputado na denúncia ao acusado Saulo é impunível, porquanto comprovado que o agente somente percorreu as etapas internas do iter criminis, sequer iniciando as práticas executivas previstas no núcleo do tipo penal que lhe foi imputado. DA ACUSADA ELIANE. DA violação À garantia da ampla defesa – perda de uma chance probatória. Excelência, em relação à acusada Eliane, deve ocorrer a absolvição em razão da incidência da teoria da "perda de uma chance probatória", perfeitamente aplicável ao Processo Penal, conforme entendimento doutrinário e posicionamento recente dos E. Tribunais. Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (grifos nossos)". A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por sua vez, assegura ao indivíduo submetido à persecução penal uma série de garantias mínimas, destacando-se a "concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa" e "direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos" (CADH, art. 8.2, alíneas c e f). Na mesma linha, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é expresso em resguardar ao imputado o direito "De dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a comunicar-se com defensor de sua escolha" e "De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e de obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições de que dispõem as de acusação" (PIDCP, art. 14.3, alíneas b e e). Tais dispositivos, portanto, conferem ao acusado um autêntico direito à prova. Amparando-se nesse referencial normativo e doutrinário, durante o inquérito, o Órgão Policial solicitou ao estabelecimento prisional que encaminhasse o pacote relativo à correspondência onde as drogas foram localizadas, a fim de que fosse realizado o competente exame grafotécnico e pudesse ser confirmado se, de fato, a escrita contida no pacote teria sido feita pela ré Eliane. Todavia, o estabelecimento prisional informou que O PACOTE EM QUESTÃO NÃO EXISTIA MAIS, tornando impossível a realização do exame (fls. 75). Se o exame grafotécnico demonstrasse o oposto, isto é, que a

correspondência

não foi escrita pelos punhos da acusada Eliane, certamente haveria uma dúvida plausível a respeito dos fatos. É nítido, pois, que a perícia em questão era importante para atestar a veracidade das declarações da acusada e, pois, provar a sua inocência. Nesse ponto, é preciso reiterar que “O direito à prova compreende [...] um poder de iniciativa em relação à introdução do material probatório no processo; trata-se do direito de proposição (indicação, requerimento) de provas [...]” (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 88, grifos nossos). Portanto, ainda que o acusado não possua o ônus de provar sua inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2), é certo que poderá defender-se provando as suas alegações. Nesse contexto, ainda que se atribua o ônus de demonstrar a autenticidade da imputação ao órgão de acusação, a defesa, sem embargo, tem o direito de produzir provas, obtendo elementos que se contraponham às alegações efetuadas pela acusação. E isso porque a condenação depende de provas irrefutáveis, além de qualquer dúvida, mas uma só contraprova ou refutação é o suficiente para justificar o convencimento oposto do julgador, conforme expõe Luigi Ferrajoli: “Enquanto nenhuma prova ou confirmação é suficiente para justificar a livre convicção do juiz sobre a verdade da acusação, uma só contraprova ou refutação é suficiente para justificar o convencimento contrário” (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad.: Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 144). Assim, diante da impossibilidade de realização do exame pericial, ocorreu, no caso concreto, a perda de uma chance (probatória), pois a acusada perdeu a chance de se mostrar inocente devido à não produção de provas pelo Estado. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo; a impossibilidade no cumprimento de uma medida que pode demonstrar a inocência do réu não pode causar-lhe um prejuízo tão grande. Portanto, tem-se que houve violação à garantia da ampla defesa, nos moldes do art. 5º, LV, da Constituição Federal, c. c/ a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8.2, alíneas c e f, e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, art. 14.3, alíneas b e e. Ante o exposto, tem-se que a hipótese acusatória não restou comprovada e, por isso, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição da acusada Eliane. Entretanto, se rejeitados todos os argumentos anteriores, verifica-se que, ainda assim, deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO EM FUNÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. Excelência, vê-se, portanto, que não há reprovabilidade no caso em exame, pois na situação em que os acusados se achavam não lhes era exigível comportamento diverso, haja vista ser fato público e notório que, muitas vezes os presos e familiares são obrigados a ingressar com esse tipo de substância em unidades prisionais para saldarem dívidas e outros débitos, sob pena de sofrerem graves represálias. Portanto, não lhes era exigível conduta diversa por parte do direito penal, já que eles não tinham escolhas razoáveis à disposição. Neste sentido, em não sendo possível praticar conduta diversa, recai sobre o caso uma excludente de culpabilidade. Ora, no desespero em que os acusados se encontravam, não viam outra saída senão ingressarem com as drogas, com a finalidade de garantir a integridade física do réu preso. Caracterizada está, portanto, a inexigibilidade de conduta diversa, causa de exclusão da culpabilidade, conforme entendimento doutrinário, sendo necessária a absolvição. Entretanto, acaso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que os acusados, à época dos fatos, eram tecnicamente primários. Ademais, não há prova de que eles participem de organização criminosa ou que se dediquem à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido, apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu. Além

disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: "Artigo 2º - Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; (...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a "integrar organização criminosa", é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: "No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida)" (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 - grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Requer-se, também, o AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. Excelência, caso não se proceda à absolvição dos acusados, de rigor reconhecer-se que o aumento gerado pelo art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 deve ser afastado, eis que a circunstância prevista no referido dispositivo legal não restou devidamente configurada na hipótese em testilha. Isso porque, para a incidência da majorante em comento, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para determinado mercado consumidor. Assim, a causa de aumento da pena somente tem lugar quando o agente, nos locais ali especificados, encontra-se com o intuito de conseguir clientela ou ampliar seu comércio de tóxicos, difundindo o vício entre doentes, estudantes ou presidiários, o que não ocorreu nesse caso. Nestes termos, o simples fato das drogas terem sido encontradas em um estabelecimento prisional (art. 40, III) não configura, por si só, a incidência da causa de aumento. Entendimento contrário traduzir-se-ia em responsabilização objetiva, vedada em nosso sistema penal. Isso porque a assunção deste tipo de responsabilidade em matéria penal importa lesão a um sem-número de princípios constitucionais, como o princípio da culpabilidade individual, a individualização da pena, a proporcionalidade das reprimendas e, no limite, o fundamento da dignidade da pessoa humana. Assim, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para aquele mercado consumidor. Desta forma, diante da flagrante impropriedade da prova em demonstrar a configuração da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, ela deve ser afastada. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a Defensoria Pública requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis aos réu, ressaltando-se que as suas vidas pregressas devem ser valoradas somente na segunda fase; (ii) na segunda fase da dosimetria, considerando que o

acusado Saulo, no procedimento administrativo disciplinar, confessou a prática do delito, postula-se, ao menos, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (ainda que extrajudicial); (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que

impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão da Resolução do Senado nº 5 de 2012 e das inúmeras decisões do Supremo (Plenário e Turmas), reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.434/06, que continha tal vedação (v.g. STF – Segunda Turma – HC nº 110.920/MG – rel. Min. Carmen Lúcia – j. 19/02/2013); (vi) seja concedida aos acusados a possibilidade de aguardarem o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista que responderam soltos a este processo e inexistiu fato concreto que justifique a decretação da prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos. ELIANA MARIA DE SOUZA NEVES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, e SAULO JOSÉ DAS NEVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 29, do Código Penal. Consta da denúncia que, em meados de abril de 2018, por volta das 12h00, no Centro de Detenção Provisória, situado na Rodovia SP 127, nº 104, Areião, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, ELIANA remeteu, com o objetivo de entrega a Saulo José das Neves, 450g de Cannabis sativa L, acondicionados em um invólucro, substância entorpecente a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, SAULO concorreu para a prática do delito acima descrito. Narra a denúncia que SAULO cumpre pena na Penitenciária de Piracicaba. No dia dos fatos, solicitou que sua mãe ELIANA lhe enviasse, por Sedex, maconha misturada com achocolatado, pois ela é cadastrada como visita e pode enviar mantimentos por correio. A ré, então, obteve quase meio quilo de maconha, misturou-a com achocolatado e remeteu a ele via Sedex. No dia 16 de abril de 2018, durante o procedimento de revista e entrega do Sedex ao detento SAULO, agentes penitenciários verificaram a presença de maconha no achocolatado em pó, remetido a ele por sua mãe ELIANA. Os réus foram notificados nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 111 e 113) e apresentaram defesa preliminar (fls. 121/125), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 126/128). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Após, os réus foram interrogados. As partes apresentaram alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 1. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05/06 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 93/95, que trouxe resultado positivo para maconha. Ouvida na fase policial, a ré ELIANA negou a prática delitiva. Disse que, na época dos fatos, seu filho estava preso no CDP de Piracicaba. Alegou que tomou conhecimento dos fatos após ter sido proibida de visitá-lo (fls. 76). Em juízo, voltou a negar a prática do crime. Disse que sequer sabe ler e escrever e nunca mandou Sedex para o filho, que estava preso. Aduziu que não fez mais visitas para ele depois do que aconteceu. O corréu SAULO, por sua vez, ouvido na fase informativa, confessou a prática do delito e eximiu a ré de culpa. Disse que estava recolhido no Centro de Detenção Provisória de Piracicaba desde 17 de outubro de 2017, indiciado pelo crime de tráfico. Narrou que, na data dos fatos, no período da tarde, estava no pavilhão A, cela 2, quando foi comunicado por um funcionário do estabelecimento prisional que sua mãe Eliane Maria de Souza Neves, enviara-lhe um Sedex. Disse que assinou um documento aceitando receber a caixa, que estava lacrada e foi aberta pelo funcionário, na sua frente. Afirmou

que, enquanto lhe entregava os pertences, o funcionário acabou encontrando maconha no meio do achocolatado. Alegou que “passou os dados da sua mãe para um companheiro que estava de alvará, que sabia das drogas, porque estava passando por dificuldades, e receberia alguns objetos”. Asseverou que a sua mãe desconhecia os fatos (fls. 34). Em juízo, alterou, em parte, sua versão. Alegou que desconhecia o conteúdo da encomenda e acreditava que sua mãe nada lhe mandou. Atestou que tampouco passou os dados dela para alguém lhe mandar a encomenda e não sabia como alguém teria tido acesso à qualificação dela. A confissão prestada em sede policial, porém, foi corroborada pelos demais elementos de prova, não há como desprezá-la. A propósito do tema os seguintes julgados: Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. (TJSP, 871392520098260050 SP 0087139-25.2009.8.26.0050, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 09/02/2012, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2012). “HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase instrutória. 2. Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal. (...)” (STJ, 115255 MS 2008/0199821-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2010). “Não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão na polícia. De mais a mais, insista-se, a confissão naquela fase merece eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilização penal do recorrente. De mais a mais, a confissão policial pode prevalecer à retratação judicial, quando harmônica com o restante da prova, uma vez que aquela vale pelo grau de credibilidade que lhe seja inerente e não pelo local em que é colhida”. (Revisão n.º 297.262/1, TACRIM, 4o Grupo de Câmaras, Relator: Luiz Ambra, RJTACRIM 35/497). O agente penitenciário Vianas relatou que o preso é chamado para receber as entregas que lhe são remetidas. Então, passam a encomenda no raio X e fazem a abertura na presença do preso. Afirmou que, ao abrir o saco de achocolatado para verificação, sentiu forte cheiro de maconha, mas mexeu no saco e não encontrou nada. Então, tiveram ideia de colocar o achocolatado na água, oportunidade em que as folhas de maconha começaram a flutuar. Disse que aquela foi a primeira vez que pegaram maconha em achocolatado com entrega pelo Sedex. Confirmou que o preso lhe falou que a maconha era transformada em pó e misturada ao achocolatado. O agente Diego afirmou que ocorrências como a dos autos são absolutamente comuns no CDP, razão pela qual não se recordava dos fatos, tendo ratificado as declarações prestadas na fase policial. É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem agentes penitenciários não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais. A prova acusatória consistente em depoimentos de agentes penitenciários é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Nesse contexto, é de rigor a condenação do corréu Saulo, nos termos da denúncia: na fase extrajudicial ele confessou, na presença de Defensor, que passou os dados de sua mãe para um colega que estava em saída temporária para que a droga lhe fosse encaminhada. E o agente penitenciário

confirmou que, ao ser encontrada a maconha, o réu falou que ela era transformada em pó e misturada ao achocolatado, evidenciando que tinha conhecimento do fato. Importa anotar que o réu concorreu efetivamente para a prática do crime, eis que passou os dados de sua mãe, que estava em seu rol de visitantes, para que terceira pessoa encaminhasse, em nome dela, o entorpecente para o estabelecimento prisional. A quantidade de entorpecente apreendida e o fato de ter sido levado para estabelecimento prisional, deixa evidente que o entorpecente se destinava ao tráfico. No que tange à corré ELIANA, os elementos de prova coligidos aos autos são insuficientes para embasar o decreto condenatório. Ela negou a prática do crime, dizendo que nunca enviou Sedex para o filho e sequer sabe ler e escrever. E o réu isentou-a de responsabilidades, alegando que passou os dados dela para terceira pessoa fazer a remessa do Sedex. E não foi produzida qualquer prova de que a ré teria enviado o Sedex, tal como exame grafotécnico, impondo-se sua absolvição, na esteira, aliás, das alegações finais do Ministério Público. 2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal. Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que SAULO ostenta maus antecedentes (autos 0001240-80.2017 da 2ª Vara Criminal local- fls. 90/92). Consigno que, para o reconhecimento dos maus antecedentes, não se exige, como para a reincidência, que o trânsito em julgado da condenação anterior seja anterior ao crime tratado, bastando que a condenação decorra de fato ocorrido anteriormente. Não importa que tenha o trânsito em julgado da condenação ocorrido depois dos eventos analisados nos presentes autos, pois o que se exige para a configuração dos maus antecedentes é que o fato seja anterior e que a condenação seja definitiva, a fim de se evitar qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência (cf. Apelação nº 0001448-64.2017.8.26.0599, Rel. Des. Newton Neves, j. 22.02.19). No mesmo sentido já decidiu o E. STJ: "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito

na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018). Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco de reclusão e quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal, para ambos os réus. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Na segunda fase de fixação das penas, não há circunstâncias agravantes. Observo, porém, que SAULO confessou a prática do delito, razão pelo qual, reduzo a pena para o mínimo legal, qual seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. A confissão espontânea, ainda que tenha sido externada apenas na fase extrajudicial, serviu de fundamento para a condenação. Logo, também deve ser considerada na segunda etapa de fixação da pena. Nesse sentido, aliás, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O DECRETO CONDENATÓRIO. HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. (...) 2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui circunstância atenuante (alínea "d" do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória. O que se deu no caso concreto. 3. Ordem concedida." (STF HC 91.654/PR 1ª T. Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 08.04.2008 DJU 07.11.2008). Na terceira fase de fixação das penas, aumento-as de um sexto, por ter sido o crime praticado nas dependências de unidade prisional, resultando cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, incabível à redução da pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo, e porque o réu já ostenta condenação pela prática de crime da mesma natureza. A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII). Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e

consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12. Porém, porque respondeu solto ao processo e não sobrevieram motivos a ensejar a custódia cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade. 3. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu SAULO JOSÉ DAS NEVES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, e no art. 40, III, da Lei 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial fechado e reconhecido o direito de apelar em liberdade, absolvendo a ré ELIANA MARIA DE SOUZA NEVES, qualificada nos autos, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do corréu SAULO. Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Custas na forma da Lei nº 11.608/03".
Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo CORRÉU SAULO JOSE DAS NEVES foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela CORRÉ ELIANE MARIA DE SOUZA NEVES foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida em relação ao corréu SAULO JOSE DAS NEVES e que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida em relação à corré ELIANE MARIA DE SOUZA NEVES.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO e para a corré ELIANE MARIA DE SOUZA NEVES.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação em relação ao corréu SAULO JOSE DAS NEVES.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória em relação ao corréu SAULO JOSE DAS NEVES, se o caso.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição em relação ao corréu SAULO JOSE DAS NEVES é 22/03/2034.

7) Oficie-se ao IIRGD comunicando a absolvição da corré ELIANE MARIA DE SOUZA NEVES.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]